

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1070/2549

พนักงานอัยการประจำศาลแขวง
สุราษฎร์ธานี

นางอุไรวรรณ แซ่เลี้ยว

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 55, มาตรา 56

ป.วิ.อ. มาตรา 193 ตรี

พ.ร.บ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 15, มาตรา 18

โจทก์อุทธรณ์โดยมีพนักงานอัยการผู้รักษาการแทนอธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูง เขต 8 รับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง โดยมีสำเนาคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 235/2546 ที่มอบหมายให้อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต หรือพนักงานอัยการผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขตมีอำนาจรับรองอุทธรณ์แทนอัยการสูงสุด เมื่อพิจารณาเห็นว่า มีเหตุอันควรที่ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยสำหรับคดีอาญาซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของอธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขตนั้น ๆ ได้ โดยเป็นคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน ป.วิ.อ. มาตรา 193 ตรี และ พ.ร.บ.พนักงานอัยการฯ มาตรา 15 พนักงานอัยการผู้รักษาการแทนอธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต 8 ตามมาตรา 18 จึงเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาจึงเป็นไปโดยชอบ

การกระทำความผิดฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ เป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบสุขของครอบครัว สร้างความเสียหายทาง

เศรษฐกิจและสังคม พุทธการณแห่งคตินับว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรง จึงสมควรรอกการ
ลงโทษจำคุกแก่จำเลย แต่จำเลยมีอายุถึง 58 ปี และโทษจำคุกที่จะต้องรับแต่ละ
กระทงมีกำหนดเวลาน้อยกว่าสามเดือน เห็นสมควรใช้ดุลพินิจกำหนดโทษจำคุกให้
น้อยลงอีกเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องแก่พุทธการณแห่งรูปคดี

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ.2478 มาตรา 4, 4 ทวิ, 5, 6, 10, 12, 15 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 33,
83, 91 ขอให้ริบของกลางและจ่ายสินบนนำจับ

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน
พ.ศ.2478 มาตรา 4, 4 ทวิ, 5, 6, 10, 12 (ที่ถูก 12 (1) และ (2)), 15 ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 33, 83 การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน
ให้เรียงกระทงลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 จำเลยให้การรับ
สารภาพหลังจากมีการสืบพยานโจทก์และจำเลยแล้ว จึงเห็นควรลดโทษให้เพียงหนึ่ง
ในสาม ฐานร่วมกันเล่นการพนันสลากกินรวบโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้รวม 196
กระทง จำคุกกระทงละ 4 เดือน ปรับกระทงละ 3,333 บาท ฐานเล่นการพนันทาย
ผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้รวม 7 กระทง จำคุก
กระทงละ 1 เดือน ปรับกระทงละ 1,000 บาท รวมจำคุก 791 เดือน ปรับ 660,268
บาท โทษจำคุกให้รอกการลงโทษไว้มีกำหนด 3 ปี ให้คุมความประพฤติจำเลยไว้
ภายในกำหนด 1 ปี โดยให้รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติจำนวน 4 ครั้งและให้
กระทำกิจกรรมบริการสังคมเป็นเวลา 30 ชั่วโมง ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตาม

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ธิปไตยกลาง และให้จำเลยจ่ายสินบนนำจับตามกฎหมาย

โจทก์อุทธรณ์ โดยพนักงานอัยการ รักษาการแทนอธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต 8 ซึ่งได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พินิจพิจารณาเห็นว่า สำหรับความผิดฐานเล่นการพนันสลากรินรวบโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ 196 กระถง ให้จำคุกกระถงละ 4 เดือน ความผิดฐานเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศโดยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ 7 กระถง ให้จำคุกกระถงละ 2 เดือน รวมจำคุก 798 เดือน ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 532 เดือน แต่ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (1) ให้ลงโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี จึงให้ลงโทษจำคุก 10 ปี โดยไม่ปรับ ไม่รอกการลงโทษและไม่คุมความประพฤติจำเลย ยกคำขอให้จ่ายสินบนนำจับนอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยฎีกาว่าพนักงานอัยการผู้รักษาการแทนอธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต 8 ไม่มีอำนาจรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลอุทธรณ์ภาค 8 จึงไม่มีอำนาจรับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณานั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตรี อธิบดีกรมอัยการหรือพนักงานอัยการซึ่งอธิบดีกรมอัยการได้มอบหมายมีอำนาจลงลายมือชื่อรับรองในคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อโจทก์อุทธรณ์ โดยมีพนักงานอัยการผู้รักษาการแทนอธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต 8 รับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง โดยมีสำเนาคำสั่งสำนักงานอัยการสูงสุดที่ 235/2546 ที่มอบหมายให้อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต หรือพนักงานอัยการผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่

อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต มีอำนาจรับรองอุทธรณ์แทนอัยการสูงสุด เมื่อพิจารณาเห็นว่ามิใช่เหตุอันควรที่ศาลอุทธรณ์จะได้วินิจฉัยสำหรับคดีอาญาซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของอธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขตนั้นๆ ได้ โดยเป็นคำสั่งที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 193 ตรี และพระราชบัญญัติพนักงานอัยการ พ.ศ.2498 มาตรา 15 พนักงานอัยการผู้รักษาการแทนอธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต 8 ตามมาตรา 18 จึงเป็นผู้ได้รับมอบหมายจากอัยการสูงสุดรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 8 รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาจึงเป็นไปโดยชอบ ฎีกาในข้อนี้ของจำเลยฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้ลงโทษในสถานเบาโดยรอกการลงโทษนั้น เห็นว่า จำเลยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ในการเล่นการพนันสลากกินรวบและทายผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ ลักษณะของการกระทำความผิดเป็นการเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนโดยมิได้คำนึงว่าจะเป็นเหตุให้ประชาชนลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุขอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปัจจุบันการพนันทายผลฟุตบอลแพร่ระบาดทั่วไปในหมู่นักเรียน นักศึกษา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบสุขของครอบครัว สร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจและสังคม พฤติการณ์แห่งคดีนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรง แม้จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน และมีภาระต้องรับผิดชอบต่อครอบครัว รวมทั้งเหตุผลความจำเป็นประการอื่น ก็ยังไม่เพียงพอที่จะรอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย อย่างไรก็ตาม ขณะกระทำความผิดจำเลยมีอายุถึง 58 ปี และโทษจำคุกซึ่งจำเลยจะต้องรับตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8 ในแต่ละกระทงมีกำหนดเวลาน้อยกว่าสามเดือนเห็นสมควรใช้ดุลพินิจกำหนดโทษจำคุกกระยะสั้นของศาลอุทธรณ์ภาค 8 ให้น้อยลงอีกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55 ทั้งนี้ เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องแก่พฤติการณ์แห่งรูปคดี ฎีกาในข้อนี้ของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยกระทงละ 3 วัน ลดโทษให้กระทงละหนึ่งในสาม ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกกระทงละ 2 วัน เรียง

กระทรวงโทษ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 รวม 203 กระทรวง คงจำคุก
จำเลย 406 วัน นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 8

(พงษ์เทพ ศิริพงศ์ติทานนท์-กิตติศักดิ์ กิตติคุณไพโรจน์-วิเชียร มงคล)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

ดุลพินิจในการกำหนดโทษให้น้อยลงอีกหรือยกโทษจำคุก คงลงแต่โทษปรับตาม
มาตรา 55 หรือการรอกการลงโทษจำคุกตามมาตรา 56 ของแต่ละชั้นศาลมีความแตก
ต่างกัน ซึ่งก็เป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาแต่ละคน ซึ่งมีอำนาจกระทำได้ตามที่
กฎหมายบัญญัติไว้ ทั้งนี้ ก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงในแต่ละคดีที่แตกต่างกัน กรณีจึง
เป็นเรื่องที่คู่ความหรือทนายความควรพิจารณาไตร่ตรองในการใช้สิทธิอุทธรณ์หรือ
ฎีกา ดังมีคดีตัวอย่างดังต่อไปนี้ แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับมาตรา 55 คำ
พิพากษาศาลฎีกาที่ 2517/2541 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โทษจำคุกที่ผู้กระทำความผิดจะต้อง
รับมีกำหนดเวลาเพียง 3 เดือน หรือน้อยกว่า ต้องถือเอาโทษจำคุกที่ลงในแต่ละ
กระทรวงความผิด จะรวมโทษจำคุกทุกกระทรวงความผิดมาเป็นเกณฑ์ในการพิจารณาหา
ได้หรือไม่ ศาลมีอำนาจใช้ดุลพินิจยกโทษจำคุกได้ในเมื่อโทษจำคุกแต่ละกระทรวงไม่เกิน 3
เดือน คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2043/2539 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้จำเลยเคยต้องโทษจำคุก
มาก่อน แต่เมื่อผู้เสียหายมีส่วนประมาทในการขับรถจักรยานยนต์ โดยไม่เปิดไฟ
หน้ารถ และจำเลยยอมชดเชยค่าเสียหายอันเป็นการบรรเทาผลร้ายแล้ว ศาลจึงลงโทษ

จำคุกและปรับแล้วยกโทษจำคุกให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55 ได้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 440/2508 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การกระทำความผิดซ้ำที่ต้องวางโทษทั้งจำทั้งปรับตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 14 ทวิ (2) นั้น แต่ศาลชั้นต้นวางโทษเพียงปรับ การที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นจำคุก 2 เดือน ปรับ 600 บาท แต่ยกโทษจำคุกเสีย ก็เป็นการพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยจึงเป็นการต้องห้ามแนวคิดพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับมาตรา 56 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1054/2543 ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าการที่จำเลยทั้ง 22 คน เข้าเล่นการพนันโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าของรับกินรับใช้ และเป็นผู้เล่นหรือลูกค้ายคนต่าง ๆ จึงต้องลงโทษบทหนักที่สุด ฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ เจ้าพนักงานจับจำเลยที่ 7 ที่ 14 และที่ 16 กับพวกได้พร้อมอุปกรณ์การเล่นการพนันหลายรายการ และยึดเงินสดได้ถึง 68,860 บาท แสดงว่าเป็นการพนันวงใหญ่ เมื่อจำเลยที่ 7 กลับมากระทำความผิดอีกในระหว่างที่รอการลงโทษในคดีก่อน จึงไม่มีเหตุสมควรรอการลงโทษ ส่วนจำเลยที่ 14 และที่ 16 ไม่ปรากฏว่าเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน อีกทั้งมีอาชีพการงานเป็นหลักแหล่ง ต้องเลี้ยงดูครอบครัว กรณีมีเหตุอันควรปรานีเพื่อให้โอกาสกลับตัวเป็นพลเมืองดี จึงสมควรรอการลงโทษให้ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2627/2540 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4 ทวิ, 5, 6, 10, 12, 15 จำคุก 8 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 4 เดือน รับของกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ปรับจำเลย 1,000 บาท อีกสถานหนึ่งลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงปรับ 500 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ไม่ชำระค่าปรับ จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่โจทก์ฎีกาขอให้ไม่รอการลงโทษจำเลยนั้น เห็นว่า การพนันทายผลฟุตบอลต่างประเทศเป็นการพนันที่มอมเมาประชาชน เป็นอบายมุขที่ก่อ

ให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศชาติ รัฐบาลมีนโยบายที่จะปราบปรามมิให้มีการเล่นหรือให้ลดลง จำเลยเป็นเจ้ามือรายใหญ่มีไพยทายผลของกลาง 4 แผ่น มีเงินที่รับแทงพนันมากถึง 27 ล้านบาท พฤติการณ์เป็นเรื่องราวแรง ไม่สมควรรอการลงโทษให้จำเลย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น" พิพากษาแก้เป็นว่า ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2388/2548 ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4, 10, 12 (ที่ถูกลบ 12 (1)) รวม 32 กระทั่ง จำคุก กระทั่งละ 3 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทั่งละกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คง จำคุกกระทั่งละ 1 เดือน 15 วัน รวมจำคุก 32 เดือน 480 วัน ธิบของกลาง คำขออื่นให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ส่วนที่จำเลยฎีกาขอให้รอการลงโทษจำคุกนั้น เห็นว่า จำเลยเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้การพนันสลากกินรวบโดยกระทำความผิดมาเป็นระยะเวลานานต่อเนื่องกันรวม 32 ครั้ง และเจ้าพนักงานตำรวจจับจำเลยได้พร้อมไพยสลากกินรวบ 80 แผ่น ซึ่งมียอดเงินในกำกับไพยสูงถึง 744,365 บาท นอกจากนี้ยังได้ยึดกระดาดทรายซื้อคนเดินไพยอีก 28 คน เงิน 1,260 บาท ปากกา 2 ด้าม และเครื่องคิดเลข 2 เครื่อง พฤติการณ์แสดงว่าจำเลยเป็นเจ้ามือการพนันสลากกินรวบรายใหญ่และกระทำเป็นอาชีพ โดยมีผู้ร่วมกระบวนกรในการกระทำความผิดหลายคนด้วยกัน นับได้ว่าเป็นการกระทำที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมเป็นอย่างยิ่ง ไม่ได้คำนึงว่าเป็นการกระทำของตนก่อผลโดยตรงให้ประชาชนลุ่มหลงมัวเมาในอบายมุขอย่างกว้างขวาง กระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความสงบสุขของครอบครัว ทั้งยังเป็นบ่อเกิดอาชญากรรมร้ายแรงอื่นตามมาอีกมากมาย พฤติการณ์แห่งคดีนี้บ่งว่าร้ายแรง การที่จะรอการลงโทษจำคุกจำเลยและกำหนดมาตรการในการคุมประพฤติแก่จำเลย จึงไม่เหมาะสมแก่สภาพความผิดและเชื่อว่าไม่เพียงพอที่จะทำให้จำเลยเกรงกลัวหรือหลาบจำ ที่ศาลอุทธรณ์

ภาค 3 ใช้ดุลพินิจไม่รอการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลยนั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย" คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 18/2549 ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291, 300, 390 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (4), 157 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบท ลงโทษฐานกระทำโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 3 ปี จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค 6 พิจารณาแก้เป็นว่า ทางนำสืบของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาคดีอยู่บ้าง มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 หนึ่งในสาม คงจำคุก 2 ปี นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ส่วนฎีกาอีกข้อขอให้ลงโทษสถานเบาและรอการลงโทษนั้น เห็นว่า จำเลยขับรถด้วยความประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย บาดเจ็บเป็นอันตรายสาหัสและเป็นอันตรายแก่กาย ศาลอุทธรณ์ภาค 6 วางโทษและลดโทษเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว แต่เหตุที่จำเลยต้องขับรถล่าเข้าไปในทางเดินรถฝั่งตรงข้าม เนื่องจากต้องหักหลบกิ่งไม้หักที่ขวางถนนในทางเดินรถของจำเลย เป็นเหตุให้รถชนกัน นางวราภรณ์ วังตาล ภรรยาของจำเลยต้องเสียชีวิต หลังเกิดเหตุแล้วจำเลยเข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวน เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับโทษจำคุกมาก่อนอีกทั้งจำเลยได้นำเงินจำนวน 200,000 บาท มาวางต่อศาลชั้นต้น ต่อมาโจทก์ทั้งสองได้รับเงินจำนวนดังกล่าวไปแล้ว โดยแถลงไม่ติดใจดำเนินคดีอาญาอีกต่อไป นับว่าเป็นการบรรเทาผลร้ายเห็นควรรอการลงโทษจำคุก เพื่อให้โอกาสจำเลย กลับตนเป็นพลเมืองดี ที่ศาลล่างทั้งสองไม่รอการลงโทษนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาข้อนี้ของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน แต่เพื่อให้หลบจำเห็นสมควรลงโทษปรับอีกสถานหนึ่ง สำหรับคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1070/2549 คดีที่เขียนหมายเหตุนี้ จำเลยถูกลงโทษฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ในการเล่นการพนันสลากกินรวบ 196 กระทง และการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศ 7 กระทง ซึ่งศาลชั้นต้น

จำคุกกระทงละ 4 เดือน ปรับกระทงละ 3,333 บาท กับจำคุกกระทงละ 1 เดือน ปรับกระทงละ 1,000 บาท ตามลำดับ รวมจำคุก 791 เดือน ปรับ 660,268 บาท ให้รอกการลงโทษจำคุกมีกำหนด 3 ปี ศาลอุทธรณ์ภาค 8 พิพากษาแก้เป็นจำคุกกระทงละ 4 เดือน และ 2 เดือน รวม 789 เดือน ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุก 532 เดือน แต่คงให้จำคุก 10 ปี ตามมาตรา 91 (1) โดยไม่ปรับไม่รอกการลงโทษ แต่ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่าให้จำคุกกระทงละ 3 วัน ลดโทษให้ 1 ใน 3 คงจำคุกกระทงละ 2 วัน รวม 203 กระทง คงจำคุก 406 วัน จะเห็นได้ว่า แต่ละชั้นศาลมีความเห็นในการลงโทษที่แตกต่างกันอย่างมาก โดยศาลฎีกาได้ใช้ดุลพินิจลงโทษจำคุกให้น้อยลงอีกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 55 กรณีเป็นที่เข้าใจได้ว่า เนื่องจากจำเลยเป็นเจ้าของรับกินรับใช้ในการเล่นการพนัน เป็นความผิดร้ายแรงและกระทำความผิดถึง 203 กระทง ศาลฎีกาจึงไม่รอกการลงโทษจำคุกให้แก่จำเลย ผู้เขียนหมายเหตุมีความเห็นว่า โทษจำคุกแต่ละกระทงที่จำเลยต้องรับมีเพียง 2 วัน เท่านั้นนับว่าเป็นโทษที่น้อยนิด หากมีการกระทำความผิดเพียง 10 กระทง หรือ 20 กระทง โทษจำคุกที่ลงจะยังคงเหมือนเดิมหรือไม่ ยังเป็นที่สงสัยอยู่ นอกจากนี้แม้การกระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อความสงบสุขของครอบครัวสร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจและสังคมก็ตาม แต่ปัจจุบันสถานการณ์และสภาพสังคมเปลี่ยนไป โดยเฉพาะรัฐบาลหรือทางราชการโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้จัดให้มีการเล่นการพนันเพิ่มมากขึ้นและอย่างแพร่หลาย ได้ดำเนินการออกสลากเช่นเดียวกับสลากกินรวบและจัดให้มีการจำหน่ายอย่างกว้างขวางทุกตรอกทุกซอกทุกซอย มียอดการจำหน่ายสูงนับเป็นพันๆ ล้านบาทต่องวด และให้เงินรางวัล (หรือแจ็กพ็อต) จำนวนสูงหลายสิบล้านบาทหรือเป็นร้อยล้านบาท เพื่อโน้มน้าวใจให้ประชาชนสนใจซื้อสลาก กรณีจึงไม่น่าจะถือเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง การลงโทษจำคุกเจ้ามือสลากกินรวบโดยไม่รอกการลงโทษให้ ก็ไม่อาจป้องกันหรือขจัดปัดเป่ามิให้มีเจ้ามือสลากกินรวบได้ การลงโทษจำคุกในระยะสั้น นอกจากจะไม่เกิดผลในการแก้ไข

ฟื้นฟูให้ผู้กระทำกลับตัวเป็นคนดีได้แล้ว ยังทำให้ผู้ต้องโทษมีประวัติเสื่อมเสียส่งผลร้ายแรงต่อตนเองและครอบครัว อีกทั้งยังอาจเป็นเหตุให้เจ้าพนักงานที่คิดจะแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อาศัยคำพิพากษาของศาลเป็นเครื่องมือในการข่มขู่เรียกรับผลประโยชน์จากผู้กระทำความผิดได้ง่ายขึ้น ผู้เขียนหมายเหตุมีความเห็นว่า การรอกการลงโทษจำคุก เสมือนเป็นชนนักติดหลัง ย่อมจะทำให้ผู้กระทำความผิดต้องตระหนก ไม่กล้ากลับไปกระทำความผิดอีกในระหว่างที่รอกการลงโทษ และศาลยังมีอำนาจที่จะคุมความประพฤติและกำหนดเงื่อนไขให้ผู้กระทำความผิดต้องปฏิบัติตามในระหว่างที่รอกการลงโทษได้ ซึ่งหากมีการกระทำความผิดอีก หรือมีการปฏิบัติผิดเงื่อนไข ศาลมีอำนาจนำโทษจำคุกที่รอมาลงได้ กรณีจึงน่าจะเป็นประโยชน์และมีผลดีมากกว่า สมเกียรติ เจริญสวรรค์